

1502340-64.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502340-64.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502340-64.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324617/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 21674297 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2333/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2324617 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

EMERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.161 ss.) e laudo pericial (fls.158 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e o réu foi interrogado e as partes se manifestaram em alegações finais em audiência.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto as preliminares arguidas, eis que não ocorreu qualquer nulidade processual, quer com leitura dos termos da denúncia, quer com a inquirição por este juízo de testemunhas e réu. Não houve, destarte, violação ao art. 212 do Código de Processo Penal.

Aliás, neste sentido a Jurisprudência:

Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento. Suposta violação do procedimento previsto no artigo 212 do CPP. Liminar indeferida. 1. Da alegação de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento. Violação do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal. A simples antecipação do juiz na produção da prova oral não expressa, de partida, uma violação do sistema acusatório, ou mesmo o comprometimento do atributo da imparcialidade. O problema não se encerra na iniciativa, mas sim na forma de sua realização. É, portanto, na forma do proceder que resta o comprometimento da imparcialidade objetiva. Foi esta a percepção que ditou a redação do art. 3-A, incorporado pela Lei 13.964/2019 e cuja eficácia foi indevidamente suspensa. O dispositivo admite a iniciativa instrutória do juiz, vedando, contudo, a "substituição da atuação probatória do órgão de acusação". A questão é, portanto, de intensidade. 2. Subtração da atuação probatória reservada ao órgão acusador não evidenciada. Violação do sistema acusatório não caracterizada. Não comprometimento da imparcialidade objetiva. 3. Nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal que incorpora dinâmica própria do processo adversarial, no qual reserva-se às partes o protagonismo na gestão do processo e, especialmente, na produção da prova. Interesse das partes na exploração dos meios de prova como forma de fixar, na mente do julgador, a sua visão sobre os fatos e os termos da imputação. 4. Hipótese em que a antecipação do juiz não representou uma inquirição antecipada ou mesmo subtração do movimento das partes, mas sim um estímulo à evocação voluntária dos traços da memória da testemunha. Não identificação de prejuízo que sequer foi especificado pela defesa em sede de recurso. Defensora que nada perguntou à testemunha dando-se por satisfeita com as respostas que haviam sido dadas à juíza e à defesa dos corréus. Nulidade não configurada. 5. Prova oral que não será submetida a conhecimento dos jurados, juízes naturais da causa, em razão do princípio da imediação probatória que vigora na sessão plenária do Tribunal do Júri. 6. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2074192-98.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Júri - 4ª Vara do Júri; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Apelação. Roubo majorado pelo emprego de faca. Recurso da Defesa. Preliminares: Nulidade da instrução por inobservância do procedimento desenhado pelo art. 212 do Código de Processo Penal. Inquirição inaugurada pelo juiz. Comprometimento da imparcialidade. Nulidade na tomada de declarações da vítima. Retirada do réu do ambiente virtual no qual era realizada a audiência. Indeferimento do pedido da defesa para inabilitação da imagem do acusado. Descumprimento do art. 217 do Código de Processo Penal. Alegação de violação da garantia da ampla defesa. Mérito: Absolvição por insuficiência de provas. Réu que teria adquirido a bicicleta sem que tivesse conhecimento da origem ilícita. Pleito subsidiário: aplicação da pena base em seu limite mínimo. 1. O marco regulatório do procedimento de produção da prova oral foi sensivelmente alterado por força da Lei 11.690/2008 que, ao superar o denominado "sistema presidencialista" de inquirição, estruturado na centralidade da atuação judicial, outorgou às partes protagonismo na exploração da prova

testemunhal. Pelo regime antigo, que deita raízes na redação original da lei processual, a inquirição era desenvolvida pelo juiz com atuação complementar das partes que, para tanto, formulavam as perguntas por intermédio da autoridade judiciária. Pelo novo modelo (art. 212 do Código de Processo Penal), cabe às partes a primazia na exploração da prova oral. Não só inauguram a inquirição, como também o fazem de forma direta e, portanto, sem a intermediação do juiz. A este compete o papel fiscalizatório. Cabe-lhe indeferir as perguntas indutoras de respostas, assim como aquelas outras que se mostrarem impertinentes ou mesmo repetidas. Ao juiz é ainda permitida a complementação da produção probatória voltada para o esclarecimento de pontos duvidosos que emergiram no contexto da inquirição.

2. No enfrentamento das situações de afronta ao novo modelo de produção da prova oral, a jurisprudência vem identificando a violação do princípio acusatório, reconhecendo, dessa forma, o comprometimento do atributo da imparcialidade do julgador. Problemática que exige apreciação mais acurada sobre o sentido e o alcance do procedimento desenhado pelo art. 212 do Código de Processo Penal, identificando-se os reais interesses tutelados pela referida norma.

3. A tradicional dicotomia acusatório/inquisitório funda-se na leitura das manifestações do processo penal calcadas pela divisão ou pela concentração dos poderes de acusar e julgar. Assim, no processo inquisitório, a concentração daqueles poderes formata uma relação processual bilateral, ditada pelo confronto entre o juiz inquisidor e o acusado. Por sua vez, no processo penal de matriz acusatória a relação assume a geometria triangular em face da divisão de poderes que lhe é própria.

4. A historiografia do processo penal revela a transposição dos processos de matriz inquisitória para aqueles de roupagem acusatória. Atualmente, mais do que a separação de poderes, a modelagem acusatória supõe uma reformatação dos poderes, funções e atividades do julgador ao longo da marcha processual reveladores dos resquícios inquisitórios.

5. A simples antecipação do juiz na produção da prova oral não expressa, de partida, uma violação do sistema acusatório, ou mesmo o comprometimento do atributo da imparcialidade. O problema não se encerra na iniciativa, mas sim na forma de sua realização. A exploração dos registros de memória da testemunha subtrai do acusador a atividade que lhe é reservada em decorrência do ônus probatório que lhe é imposto pelo princípio constitucional da presunção de inocência. É, portanto, na forma do proceder que resta o comprometimento da imparcialidade objetiva. Foi esta a percepção que ditou a redação do art. 3-A, incorporado pela Lei 13.964/2019 e cuja eficácia foi indevidamente suspensa. O dispositivo admite a iniciativa instrutória do juiz, vedando, contudo, a "substituição da atuação probatória do órgão de acusação". A questão é, portanto, de intensidade.

6. Hipótese em que o juiz, após tomar o compromisso de uma das testemunhas, que havia sido arrolada pela acusação, convidou-a a fazer uma breve exposição sobre os fatos que se recordava. Após o breve relato, deu-se oportunidade às partes para a inquirição direta da testemunha. Conduta legal e perspicaz da autoridade judiciária. De um lado, buscou estimular a testemunha à evocação espontânea de sua memória. Cuida-se de importante técnica que minimiza os riscos das falsas memórias. De outro, buscou assegurar a observância dos limites dados pelo thema probandum. Subtração da atuação probatória reservada ao órgão acusador não evidenciada. Violação do sistema acusatório não caracterizada. Não comprometimento da imparcialidade objetiva.

7. Nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal que incorpora dinâmica própria do processo adversarial, no qual reserva-se às partes o protagonismo na gestão do processo e, especialmente, na produção da prova. Interesse das partes na exploração dos meios de prova como forma de fixar, na mente do julgador, a sua visão sobre os fatos e os termos da imputação.

8. Hipótese em que a antecipação do juiz não representou uma inquirição antecipada ou mesmo subtração do movimento das partes, mas sim um estímulo à evocação voluntária dos traços da memória da testemunha. Não identificação de prejuízo que sequer foi especificado pela defesa em sede de recurso. Defensor que nada perguntou à testemunha dando-se por satisfeito com as respostas que haviam sido dadas à acusação. Nulidade não configurada.

9. Alegação de nulidade na oitiva da vítima. Audiência realizada em ambiente virtual. Pedido da ofendida para depor sem a presença do acusado. Retirada do réu da sala de audiência virtual, com fundamento no art. 217 do Código de Processo Penal. Oportuna

insurgência defensiva pleiteando que o acusado acompanhasse a audiência em sua íntegra, inabilitando a sua imagem de modo que a vítima não pudesse enxergá-lo durante a colheita de suas declarações. Indeferimento. 10. A nova redação dada ao artigo 217 do Código de Processo Penal pela Lei 11.690/2008 buscou conferir efetividade ao exercício da autodefesa, manifestada pelo direito de presença. Restrição ao exercício do direito que ficou jungida ao plano da excepcionalidade. Critérios de ponderação indicados pelo legislador. Temor, humilhação ou sério constrangimento que justificam a ruptura do quadro assecuratório da autodefesa. Retirada do réu da sala de audiência que se expressa, no plano normativo, como última providência, caso inviabilizada a tomada das declarações por videoconferência. 11. Dispositivo que não foi elaborado para uma realidade de proeminência das audiências virtuais. Imersão das atividades judiciais no modo telepresencial que se tornou compulsória diante das medidas de isolamento impostas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. 12. Delimitação de novo padrão de aproximação e de concretização das relações humanas que, muito embora antevisto em face do curso normal dos avanços tecnológicos, foi sensivelmente acelerado nos últimos dois anos. Distanciamentos físicos que foram reaproximados pelo campo virtual. Estabelecimento de novos padrões de relações e de inter-relações que ganharam contornos de normalidade. O compartilhamento de imagem e de som encurta distâncias, tornando a experiência bastante real, como de fato o é. Assunção coletiva e individual de um novo padrão de normalidade. 13. Sensibilidade do julgador para as situações-limite em que o temor, a humilhação e o grave constrangimento não serão totalmente afastados pelo fato de se realizar audiência telepresencial. Cita-se, a título exemplificativo a vítima de abuso sexual que, compreensivelmente, poderá se sentir constrangida a prestar declarações, sabedora que o pretendo autor está a ouvi-la. Situação que também pode se verificar na oitiva da vítima de atos extremamente violentos como tortura, sequestro ou extorsões. Abertura de canais de ponderação à autoridade judiciária. 14. Normativa internacional proclamatória da afirmação dos espaços de resguardo da dignidade humana da vítima. Declaração dos princípios básicos de Justiça relativos às vítimas de criminalidade e abuso de poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 40/34, de 29 de novembro de 1985. Dever imposto às autoridades para tratamento das vítimas, orientado pela compaixão e pelo respeito da dignidade (art. 4º do Anexo da Declaração) Norte hermenêutico que deve ser sopesado pela autoridade judiciária na resolução das situações-limite de conflito de interesses com a garantia da autodefesa. 15. Hipótese em que a ponderação realizada pela autoridade judiciária atendeu aos critérios da razoabilidade. Ação criminosa que envolvia roubo mediante violência e ameaça com emprego de faca. Vítima que foi novamente ameaçada pelo acusado no distrito policial quando dos procedimentos de lavratura do auto de prisão em flagrante. Temor fundado da vítima, cidadã comum. Risco de comprometimento das declarações. Afastamento justificado do acusado do ambiente virtual. Resguardo da ampla defesa com a presença do defensor técnico e do exercício efetivo da defesa. Nulidade afastada. 16. Mérito recursal. Condenação correta. Declarações da vítima e depoimentos dos guardas civis que se pautam pela coerência e uniformidade. Apreensão da faca utilizada pelo acusado durante a ação delituosa. Versão ofertada pelo acusado em juízo que foi amplamente contrariada pela prova oral. Intenção de falseamento dos fatos pela vítima e pelas testemunhas não evidenciada. Fatos que se subsumem ao tipo penal do roubo. Emprego de grave ameaça e violência física. 17. Dosimetria que comporta reparos. Réu que ostenta antecedentes criminais. Circunstância judicial desfavorável. Modulação do aumento. Pena base que é aplicada com o aumento de 1/6. Reincidência demonstrada. Manutenção do aumento de 1/6 operado

na segunda fase. Possibilidade de consideração de distintas condenações nas diferentes fases da dosimetria. Precedentes do STJ. Manutenção do aumento de 1/3 na terceira fase em razão do emprego de arma branca. Preservação do regime fechado. 18. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500315-67.2020.8.26.0546; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Quanto a outra preliminar arguida pela douda Defesa não procede. De fato, como já entendeu o E.TJSP (acórdão 1500390-78.2021.8.26.0544): "De acordo com o CPP, artigo 301, qualquer um do povo pode efetuar a prisão de quem estiver em flagrante. Tal previsão também se encontra na Lei 13022/14, que, em seu artigo 5º, inciso XIV, trata dos guardas municipais, estabelecendo, expressamente, a competência para prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado".

Aos guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de agir para evitar a ocorrência de crimes, sendo que a omissão poderia levar a eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. "Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem sucedida, perpetrada por guardas civis, em observância à legislação pátria pertinente. O delito de tráfico em análise é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa.

Além disso, a apreensão das drogas configura o estado de flagrância, que autoriza a prisão dos suspeitos pelos guardas municipais, bem como a instauração do inquérito policial e a justa causa para a ação penal, não havendo que se falar em rejeição da denúncia. O caso em exame, portanto, não retrata situação em que a guarda municipal executou atividade investigatória, típica de polícia civil. Ora, ao tomarem conhecimento dos fatos pela indicação de uma denúncia anônima, os guardas se dirigiram até o local, uma via pública, onde o crime era cometido à vista de todos, e surpreenderam os acusados em situação de flagrância. E, quanto ao mérito, em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa, a ação penal é procedente.

O GCM George de Lima informou que receberam uma denúncia anônima acerca do tráfico de entorpecentes no local e foram até lá averiguar a denúncia; informou que eles são obrigados a averiguar denúncia da prática de eventuais crimes; lá chegando, deparou com o réu, o qual estava sozinho e estava com uma sacola nas mãos. Assim que ele avistou a viatura, ele largou a sacola e tentou se evadir, mas foi detido; as drogas estavam na sacola e embaladas; com o réu foi encontrada uma quantia em dinheiro. Foi seu parceiro quem conversou com o acusado. O local já é conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. Não conhecia o réu anteriormente. O réu, ao ser interrogado, admitiu os fatos; disse que na verdade exercia a função de "olheiro" e que realmente estava com a sacola nas mãos quando foi abordado pelos guardas civis; disse que estava passando por necessidades, pois sua filha ia nascer e estava desempregado e aceitou o convite para participar do tráfico de entorpecentes pelo valor diário de R\$ 100,00; afirmou que era seu segundo dia exercendo a função; não tem outras passagens, mora com a mãe e sempre trabalhou. Portanto, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu estava em local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas e foi surpreendido pelos guardas civis com as drogas em seu poder.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSP 179/152).

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.158 ss. e pelos demais autos de apreensão juntados aos autos.

O réu é primário, de sorte que faz jus a aplicação da pena em seu mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do que estatui o art.33§3º do Código Penal. Deixo de diminuir a pena em razão da confissão e da menoridade, eis que se trata de mera atenuante genérica e o crime já foi fixado em seu mínimo legal.

De fato, trata-se de crime grave, verdadeiro flagelo social, dos mais reprováveis, equiparado ao hediondo e que demanda pronto combate e repressão pelos poderes

constituídos e a segregação de seu agente do seio da sociedade. Deixo de diminuir a pena nos termos do que dispõe o art. 33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores. Ademais, é preciso levar em consideração a vultosa quantidade de drogas apreendida, bem como a variedade de entorpecentes encontradas com o réu (maconha, crack e cocaína).

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE XASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a

concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO

DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019)." (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019).

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal. Quanto a detração penal, efetivamente parece mais razoável relegar sua análise ao juízo da execução; de qualquer foram, evidentemente que o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente será considerado para fins de detração penal e, no presente momento, a detração ainda não importaria em concessão de regime prisional menos gravoso.

Praticou ele crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, dos mais reprováveis e denota envolvimento com a criminalidade e falta de senso de responsabilidade, motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno EMERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO SILVA, já qualificado, a 05 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06 c.C.Art65, inciso I e III, letra "d" .

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA